

1500229-02.2022.8.26.0587

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente ter em depósito e guardar, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500229-02.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500229-02.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DE CASTRO BRANDÃO

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 90/91, no dia 22 de março de 2022, por volta das 18h, na Rua Tropicanga, 56, Boiçucanga, nesta cidade Comarca de São Sebastião, KAIQUE DE CASTRO BRANDÃO, qualificado nos autos, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 305 invólucros de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 78,60g (setenta e oito gramas e sessenta centigramas), além da quantia de R\$ 100,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação prévia de fls. 11.

Em razão destes fatos, o réu foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 79/80), o réu citado pessoalmente (fls. 88) e apresentou resposta à acusação às fls. 94/96.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 97/101), em instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha, bem como procedido ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação do réu, nos termos da acusação (fls. 25).

A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade de provas em razão da ilegalidade da

busca e apreensão ocorrida na residência do réu. Pugnou ainda pela absolvição dos réus por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto; reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; bem como aplicação do redutor referente ao tráfico privilegiado, substituindo-se a pena privativa por restritiva de direitos. Requereu ainda o reconhecimento da causa de diminuição presente do artigo 41 do mesmo diploma legal. Postulou ainda pela isenção da pena de multa bem como pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 125).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação preliminar das Defesas, sobre nulidade da ação policial quando do ingresso na residência do réu sem a sua permissão, onde se encontravam também os entorpecentes apreendidos. O resguardo do domicílio é direito constitucional, que cede passo à ação estatal motivada pela segurança pública, quando se trata de flagrante delito. É a exata situação deste caso. O ingresso dos policiais militares na casa revelou-se suficientemente calcado em justa causa, diante das circunstâncias da diligência e as explicações a posteriori pelos milicianos, tanto na delegacia quanto em audiência. Diante de suspeita fundada de crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, considero que a ação policial foi necessária e legítima.

Nesse sentido a jurisprudência recente do STJ:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Inexistência de ilegalidade na colheita das provas a partir do ingresso da polícia no local tido como servidão de passagem para a propriedade rural do corréu. 2. O imóvel no qual ocorreram as buscas e a apreensão de 919 kg de maconha nem sequer pode ser caracterizado como domicílio ou local de residência do corréu. 3. A atuação policial não decorreu unicamente de denúncia anônima; existiam também fundadas razões de que, no local, estava sendo cometido crime de tráfico de drogas. A entrada dos policiais na propriedade em questão deu-se de forma lícita, após investigação prévia, em situação de flagrância e urgência, não se verificando nenhuma ilegalidade. 4. Correto o restabelecimento da prisão preventiva, dada a gravidade concreta dos fatos em apuração e a periculosidade do agente, manifestada pela reiteração delitiva, ficando superada a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da medida, sobretudo porque os registros criminais disponíveis indicam a dedicação longa e contínua do paciente à prática de ilícitos penais. 5. Ordem denegada. Pedido de reconsideração da decisão liminar prejudicado. (HC 718056/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, j. 10/05/2022).

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência de fls. 07/09, no auto de exibição e apreensão de fls. 10, auto de constatação preliminar de fls. 11, nas imagens de fls. 12/13 e no laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 114/115, que revelou resultado positivo para a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Kaique negou a prática delitiva, alegando que estava na porta de sua casa e antes de chegar a sua casa, passou na mercearia e portava a nota de cem reais e comprou um maço de cigarro, mas o rapaz estava sem troco e retornou para casa com o dinheiro e o maço de cigarros, sendo que foi abordado pelos policiais na frente de sua casa e "forçaram" a adentrar na sua residência. Indagaram se havia dinheiro e drogas para, porém disse que não existia. Realizaram as buscas e disseram que encontraram drogas no armário da cozinha, imputando a ele a propriedade, mas nega. Confirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, que entraram a força, com a arma apontada para ele.

Não viu a droga apreendida.

Fábio Rodrigo Biazzi Fonseca, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estamos em patrulhamento pela estrada do cascalho e abordaram um indivíduo que se

identificou como usuário de drogas, sendo que ele relatou para a equipe que Kaique havia recebido drogas na sua residência de um traficante conhecido como "Aba". Como já havia denúncias sobre Kaique, na traficância, juntamente com a mãe dele, deslocaram-se para o endereço e visualizaram o Kaique de frente a residência dele. Ele estava de costas para o sentido da equipe e realizaram a abordagem, sendo localizado no bolso da bermuda dele, quatro porções de crack e R\$ 100,00. Indagado, ele acabou confirmando a veracidade de que havia recebido drogas mesmo, mas não indicou de quem e que estava armazenada na sua casa. Foram levados até o local e ele apontou onde estavam os entorpecentes, no interior do guarda roupa, onde localizaram um saco preto, com mais de 300 pedras de crack e que ele vendia a R\$10,00 cada. Esclareceu que as drogas encontradas com ele estava embaladas da mesma forma que as encontradas no interior do armário, de forma individual. Já abordou Kaique anteriormente, mas nada de ilícito foi encontrado. Não havia outras pessoas nas proximidades e o próprio réu autorizou a entrada dos policiais. Acrescentou que a denúncia era sobre Kaique e sua genitora, a qual foi presa em flagrante delito por tráfico no mesmo local, aproximadamente 15 dias após a prisão do réu.

No mesmo sentido o depoimento do policial João Carlos Duque da Silva, o qual confirmando que encontraram 4 pedras de crack com Kaique e ele franqueou a entrada dos policiais na residência dele. Acresceu que durante revista no interior do imóvel, ele percebeu que iriam encontrar o restante da droga, momento em que ele confessou que havia mais drogas e disse que estava no interior do guarda-roupa, no quarto dele, onde localizaram a quantia de 301 pedras de crack. Não encontraram nenhum tipo de arma, pois a denúncia anterior informava que ele também andava armado. Confirmou que 15 dias após essa prisão dele, a mãe dele também foi presa pelo mesmo delito. Esclareceu que as drogas encontradas com ele estava embaladas da mesma forma e mesmo tipo que as encontradas no interior do armário. Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais, ouvidos em juízo confirmaram a prática do tráfico de drogas por parte do réu e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho dos agentes públicos, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Anoto que a quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas com o réu e em local por ele indicado (305 invólucros de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 78,60 g), a forma de acondicionamento das substâncias, todas individualizadas e embaladas prontas para a venda e o consumo, o local onde se deram os fatos, ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, prévia denúncia anônima, formalmente materializada às fls. 59, além do depoimento das testemunhas, evidenciam que as substâncias apreendidas eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória.

Neste ponto, destaco que os relatos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. Não é demais explicitar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente ter em depósito e guardar, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de

tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme FA e certidão de fls. 77 e 78. Quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas com o acusado, ainda que notadamente relevantes, serão apenas sopesadas na terceira fase da dosimetria a fim de evitar possível bis in idem.

Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante referente à menoridade relativa, a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse a atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Diminuo a pena na fração de 1/2, fração intermediária, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do acusado, em especial cocaína em forma de crack, droga com alto poder vulnerante e elevado potencial de causar dependência química aos seus usuários, resultando assim a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Por fim, descabida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei 11.343/06. Embora os policiais tenham dito que o réu colaborou na localização dos entorpecentes, sua participação é incompatível com a finalidade pretendida pelo legislador. O objetivo do dispositivo legal é a obtenção do desmantelamento das associações criminosas, pelo que apenas eventual indicação pelo réu acerca do fornecedor das substâncias por ele armazenadas poderia, eventualmente, acarretar a aplicação da causa de redução, o que não ocorreu no caso em tela. É o que se observa da redação do dispositivo legal, o qual traça requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena. Assim, a despeito dos bem lançados argumentos da Defesa, tenho por descabida a interpretação segundo a qual os requisitos estabelecidos no artigo 41 da lei especial para o deferimento do privilégio têm caráter alternativo.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §§ 2º e 3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput, e § 2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado KAÍQUE DE CASTRO BRANDÃO, qualificado nos autos, à pena privativa corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime prisional inicial aberto, e a 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída, entretanto, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

O réu não apresentou prova da origem lícita do valores com ele apreendidos, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se o necessário para intimação pessoal do sentenciado, bem como quanto à destinação dos valores e das drogas apreendidos, independentemente do trânsito em julgado.

Oficie-se à Delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas, inclusive as reservadas para contraprova.

Condeno, ainda, o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

Transitada em julgado a presente decisão, tornem conclusos.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA